

1500224-61.2022.8.26.0366

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Comarca: Mongaguá

Foro: Foro de Mongaguá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 01/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS MORRISEY SANTOS SILVA

Réu Preso

Juiz Substituto: Dr. ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Relatório

Cuida-se de ação penal pública promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra MATHEUS MORRISEY SANTOS SILVA imputando-lhe a prática do crime tipificado no artigo 33, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mongaguá

Foro de Mongaguá

1ª Vara

Avenida São Paulo, 300, Mongaguá (SP) - cep 11730-000

1500224-61.2022.8.26.0366 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500224-61.2022.8.26.0366

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS MORRISEY SANTOS SILVA

Réu Preso

Juiz Substituto: Dr. ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Relatório

Cuida-se de ação penal pública promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra MATHEUS MORRISEY SANTOS SILVA imputando-lhe a prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Sustenta a denúncia que, no dia 26 de abril de 2022, por volta das 04h, na Avenida José Cesário Pereira Filho, altura do nº 1600, Vila Vera Cruz, nesta cidade e comarca de Mongaguá, o acusado transportava, para fins de tráfico, 5320 pedras de crack, com peso bruto de 1438g, 3388 porções de cocaína, com peso bruto de 7615g e 17640 porções de maconha, com peso bruto de 16895g, conforme auto de exibição/apreensão de fls. 10/11 e auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 12/13.

Narra que o acusado, nas circunstâncias objetivas de tempo e lugar acima descritos, o acusado transportava entorpecentes em favor de um indivíduo de alcunha "PH", desde a cidade de Santos até este município de Mongaguá. Quando passava pelo local dos fatos, se deparou com uma guarnição da polícia militar que atendia a outra

ocorrência, passando a apresentar certo nervosismo, e tentou se evadir de marcha à ré. No entanto, em razão da atitude francamente suspeita, foi abordado pelos armigeros. Com o acusado, os servidores da lei encontraram uma porção de maconha e a quantia de R\$ 7,00. Ainda, notaram forte odor vindo do porta-malas do automóvel, onde localizaram os estupefacientes já mencionados. As circunstâncias da abordagem, as atitudes dos acusados, o local dos fatos e a apreensão de expressiva quantidade de drogas de naturezas diversas dão conta que o acusado praticava a mercancia ilícita de entorpecentes.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 53/56).

Laudos acostados a fls. 249/251.

A denúncia foi recebida (fls. 53/56) e o réu foi citado (fls. 53/56), apresentou resposta à acusação a fls. 66/69 e 166/175.

Em audiência foram colhidos os depoimentos das testemunhas e realizado o interrogatório, em que o acusado alega que estava transportando a sacola, tendo sido contratado para tanto, mas não tinha ciência do conteúdo.

Em alegações finais, o Ministério Público (fls. 310/319) pugna pelo acolhimento da pretensão acusatória, com valoração na fixação da pena da elevada quantidade de droga e afastamento da figura privilegiada pelo mesmo motivo, consideradas as circunstância, ainda, da infração, com o transporte intermunicipal da droga, e com regime inicial fechado.

A defesa técnica (fls. 338/353) suscitou a nulidade da busca pessoal e no veículo, ausente justa causa para tanto, e pugna pela absolvição do acusado ante o erro de tipo quanto ao conteúdo da encomenda transportada, não sabendo o acusado se tratar de droga. Subsidiariamente, requer a aplicação da atenuante da confissão e o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Folha de antecedentes e certidão de distribuição estão a fls. 39/40 e fls. 41/42.

Fundamentação

Preliminar

De acordo com os artigos 240, parágrafo 2º, e 244 do Código de Processo Penal, autoriza-se a busca pessoal, independentemente de mandado judicial, no curso de busca domiciliar. Ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Em diversos termos, quando houver indícios suficientes de que a pessoa porte consigo coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos, armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso, objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu, e cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato ou qualquer outro elemento de convicção.

É certo que "os arts. 240, § 2.º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, exigem que haja fundada suspeita, e não mera impressão subjetiva, sobre a posse de objetos ilícitos para que seja possível a referida diligência. Esta fundada suspeita deve, portanto, ser objetiva e justificável a partir de dados concretos, independentemente de considerações pessoais acerca do "sentimento", "intuição" ou o "tirocínio" do agente policial que a executa." (REsp n. 1.953.889/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

No caso, conforme atestado pelos policiais militares, foi feita a abordagem e a revista pessoal porque, estando os policiais em via pública, o veículo conduzido por MATHEUS parou subitamente, tendo o motor desligado. Ato contínuo, o acusado tentou dar marcha ré, desviando-se do local em que se encontravam os policiais, sem motivo aparente. E, por fim, uma vez estabelecida conversa com o condutor, visualizaram um cigarro de maconha no painel.

Tudo o que, segundo se crê, dava fundadas razões para a realização da revista pessoal e veicular, não havendo qualquer nulidade a reconhecer nas provas daí derivadas.

Existência e Autoria

No mais, a existência da ação criminosa restou demonstrada pelas provas documental, pericial e oral produzidas.

As declarações dos policiais em juízo confirmam a apreensão de substâncias nos

termos do auto de apreensão, em que o perito oficial detectou a presença de tetrahydrocannabinol (THC) e cocaína.

A própria quantidade de droga apreendida, bem superior ao que normalmente se destinaria ao consumo próprio de um usuário da droga, corrobora a versão acusatória no sentido de que seu destino não era o consumo pessoal, mas a entrega a terceiros. Nos moldes do artigo 28, parágrafo 2º, da Lei 11.343/06, “para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Para apreciação do vetor objetivo da natureza e quantidade da droga adota-se como parâmetro um consumo diário individual médio de até 2,5g de maconha (cerca de 2 a 4 cigarros), de até 16 pedras de crack (cerca de 5,2g) e de até 0,2g de cocaína, conforme a Portaria 94/1996 dos Ministérios da Justiça e da Saúde de Portugal, sugerida por Maria Tereza Uille Gomes, então Secretária de Estado da Justiça Cidadania e Direitos Humanos do Paraná (Estudo Técnico para Sistematização de Dados sobre Informações do Requisito Objetivo da Lei nº 11.343/2006, 2014).

Tal quantidade é compatível com o uso semanal médio de 14 cigarros de maconha referido em pesquisa com 80 dependentes da maconha do ambulatório do Grupo Interdisciplinar de Estudos de Álcool e Drogas da Faculdade de Medicina da USP (Hercilio Pereira de Oliveira Junior, Avaliação do perfil de comorbidades, gravidade da dependência e motivação para o tratamento em uma amostra de usuários de maconha que procuram tratamento, Mestrado, USP, 2010); e com o uso de até 2g por episódio relatado por 58% de 86 usuários de maconha atendidos no Centros de Atenção Psicossocial e no Hospital de Clínicas da Unicamp em Campinas (Karina Diniz Oliveira, Perfil sócio demográfico, padrão de consumo e comportamento criminoso em usuários de substâncias psicoativas que iniciaram tratamento, Mestrado, UNICAMP, 2010).

Quanto ao crack, tal quantidade de consumo individual acima referido é compatível com o padrão médio de uso no Brasil de 13,42 porções por dia apurado por pesquisa da FIOCRUZ, idealizada em conjunto com a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Pesquisa Nacional sobre o Uso do Crack, 2014); com o uso de mais de 10 pedras por episódio relatado por 47% de 67 usuários de crack atendidos no Centros de Atenção Psicossocial e no Hospital de Clínicas da Unicamp em Campinas (Karina Diniz Oliveira, Perfil sócio demográfico, padrão de consumo e comportamento criminoso em usuários de substâncias psicoativas que iniciaram tratamento, Mestrado, UNICAMP, 2010); com o relato de uso de uso de 10 ou mais pedras por 69,5% de 67 usuários de crack atendidos nos Centros de Atenção Psicossocial de Igrejinha, Taquara e Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul (Rogério Lessa Horta et al, Perfil dos usuários de crack que buscam atendimento em Centros de Atenção Psicossocial. Cad. Saúde Pública, v. 27, n. 11, p. 2263-2270, 2011); e com a média de 73,2 pedras de crack por semana encontrada em pesquisa com 72 pacientes do Centro de Atenção Psicossocial de Serra, no Espírito Santo (Janine Andrade Moscon, Avaliação dos padrões de consumo de crack, cognição global e de funções executivas em usuários de ambulatório especializado de alta demanda, Mestrado, UFES, 2013).

Quanto à cocaína, tal quantidade de consumo individual acima referido é compatível com o uso de 2g de cocaína por mês um dos vetores para a definição de dependência em pesquisa estadunidense que apurou, ainda, consumo médio mensal de 0,8g de cocaína entre todas as 2.349 pessoas que disseram ter consumido a droga entre 1991 e 1993 (Kevin Chen e Denise Kandel, Relationship between extent of cocaine use and dependence among adolescents and adults in the United States, Drug and Alcohol Dependence, v. 68, 2002), mas é subestimada frente ao uso de até 2g a 5g por episódio relatado por 47% de 87 usuários de cocaína atendidos no Centros de Atenção Psicossocial e no Hospital de Clínicas da Unicamp em Campinas (Karina Diniz Oliveira, Perfil sócio demográfico, padrão de consumo e comportamento criminoso em usuários de substâncias psicoativas que iniciaram tratamento, Mestrado, UNICAMP, 2010), de modo que aquele valor não deve ser tomado de modo absoluto e deve ser sopesado, por exemplo, com o grau de pureza da droga – ainda assim, no caso, a quantidade é realmente expressiva e desborda do consumo pessoal.

E a autoria delitiva também restou comprovada pelos elementos probatórios colhidos, somando-se à confissão, posto que parcial, dos acusados.

Com efeito, as testemunhas ouvidas atestaram ter sido o acusado abordado na condução de veículo automotor transportando as drogas para outro Município. O policial militar Jackson disse que na data dos fatos fizeram abordagem de indivíduo na Rua Engenheiro de TAL e MATHEUS conduzia um veículo. O carro morreu e, aproximando-se, MATHEUS tentou dar marcha ré, razão de realizarem abordagem. Disse que era um motorista de UBER, mas visualizaram no painel um cigarro de maconha. Perguntado, MATHEUS disse que era usuário e tinha acabado de fazer uso de droga. Pediu para que abrisse o porta-malas, local em que encontrou um saco contendo a droga. A droga estava embalada individualmente e acondicionada em sacos pretos. Era uma grande quantidade de droga, num total de 27kg. Informalmente, o acusado só falou que era motorista de uber e que não sabia o que estava transportando, não conhecia o teor, mas tinha sido contratado para levá-la para Mongaguá. Perguntado, confirmou que havia um odor forte de droga quando da abordagem. MATHEUS tentou virar no cruzamento, estava descendo a Rua Tal e, virando a esquina, se deparou com a equipe policial. Estavam, antes, fazendo patrulhamento e um indivíduo corria, sem encontrar nada com ele. Contudo, neste momento, o veículo conduzido por MATHEUS se aproximou e veio a morrer, o que motivou a abordagem. Confrontado sobre a divergência quanto ao momento em que sentiu o odor, disse que mediante a aproximação do veículo sentiram o cheiro de droga. Antes de determinar a parada não tinha sentido qualquer odor.

O policial militar Lucas disse que estava em patrulhamento e fazendo uma abordagem envolvendo um ou dois indivíduos já de costume quando um veículo GOL adentrou a via em que estavam e veio a morrer. O motorista tentou dar marcha ré, demonstrando nervosismo, razão de realizarem a abordagem. Dentro do carro encontraram uma porção de maconha e, ao pedir para abrir o porta-malas, visualizaram sacos pretos contendo droga em seu interior. Tinha cocaína, a crack e maconha, num total de 27 quilos. Informalmente, MATHEUS disse que estava fazendo o serviço de transporte e sabia que era droga, mas não que era tanta droga. Foi contratado para trazer a droga para Mongaguá. Perguntado, confirmou que sentiu odor de maconha forte quando se aproximou do veículo. Confirma que, para ele, MATHEUS disse saber se tratar de droga.

Em seu interrogatório judicial, o acusado admite ter sido contratado para realizar o transporte da droga, limitando-se a dizer que não conhecia o conteúdo do pacote. Como se sabe, “o dolo é a vontade consciente de realizar um crime ou – mais tecnicamente – a vontade consciente de realizar o tipo objetivo de um crime, também definível como saber e querer em relação às circunstâncias de fato do tipo legal. Assim, o dolo é composto de um elemento intelectual (consciência, ou representação psíquica) e de um elemento volitivo (vontade, ou energia psíquica), como fatores formadores da ação típica dolosa” (Juarez Cirino dos Santos, Direito Penal – Parte Geral, 5ª ed., 2012, p. 126). É dizer, o dolo se caracteriza no estágio meramente subjetivo (interno, psíquico) do comportamento humano. Por isto, a sua aferição se faz a partir das circunstâncias que cercam a conduta do agente, do contexto externo de seu comportamento, assim a partir da prova indiciária de que trata o artigo 239 do Código de Processo Penal.

No caso, as condições de tempo e lugar, as circunstâncias em torno da apreensão e mesmo o teor de seu depoimento são suficientes para comprovar o dolo, assim de que estivesse o acusado bem ciente do transporte de expressiva quantidade de droga. Primeiro que, enquanto suposto motorista de aplicativo, não se dedica à atividade de transporte de encomendas, mas de pessoas. Depois, retirou as três sacolas de madrugada, de pessoas nunca identificadas, para entregar a terceiro igualmente não identificado, tudo por valor acima do de mercado. Enfim, tudo a indicar ser de todo inverossímil a versão da autodefesa. De se lembrar, aliás, que a cegueira deliberada não é apta a excluir o dolo.

A propósito do valor do depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, realmente, ao que se entende, a presunção de legalidade do ato administrativo não se aplica à esfera penal, norteadas pela estrita presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), devendo a pretensão

acusatória ser comprovada em juízo por elementos intersubjetivos.

Em outras palavras, o Estado de Direito exige algo mais para legitimar a privação de direitos do que a palavra dos agentes policiais (v. *mutatis mutandis* HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021), o que está presente no caso concreto consoante os demais elementos de prova já valorados.

Conforme a lição de Aury Lopes Jr., “não há que se falar em restrição ao depoimento dos policiais. Eles podem depor sobre os fatos que presenciaram e/ou dos quais têm conhecimento, sem qualquer impedimento. Obviamente, deverá o juiz ter muita cautela na valoração desses depoimentos, na medida em que os policiais estão naturalmente contaminados pela atuação que tiveram na repressão e apuração do fato. Além dos prejulgamentos e da imensa carga de fatores psicológicos associados à atividade desenvolvida, é evidente que o envolvimento do policial com a investigação (e prisões) gera a necessidade de justificar e legitimar os atos (e eventuais abusos) praticados. Assim, não há uma restrição ou proibição de que o policial seja ouvido como testemunha, senão que deverá o juiz ter muita cautela no momento de valorar esse depoimento. A restrição não é em relação à possibilidade de depor, mas sim ao momento de (des)valorar esse depoimento.” (Direito Processual Penal, 18ª ed., Saraiva, 2021, p. 529).

No caso, a narrativa policial está em consonância com a confissão parcial havida, como se disse, e com as circunstâncias em que realizada a prisão em flagrante. Enfim, nestes termos, restaram confirmadas as teses de fato da acusação e “não há elementos de prova que tornem viável ter ocorrido fato concreto diverso de qualquer proposição fática que integre a imputação.” (Gustavo Badaró, *Epistemologia Judiciária e Prova Penal*, RT, 2019, p. 259).

Adequação Típica

Prevista na lei penal, a conduta do acusado também é materialmente típica, pois causa expressiva lesão, ainda que potencial, ao bem jurídico penalmente protegido. Por consequência, a severa intervenção penal não viola o direito constitucional à liberdade, atendido o postulado da proporcionalidade.

A acusação não logrou demonstrar que o agente seja reincidente, tenha maus antecedentes, se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa, razão pela qual aplicável a causa de diminuição de pena do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06.

Ao contrário, o único elemento nesse sentido foi a folha de antecedentes, que indica a primariedade do acusado.

Note-se que a apreensão de quantidade não módica de droga em poder do acusado não é indício suficiente para, isoladamente, permitir se conclua que a acusada se dedica às atividades criminosas, pois daí não se extrai conclusão segura (STF, HC 138138, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 29/11/2016), a menos que se trate de quantidade realmente exorbitante ou que haja outros indícios, o que não é o caso.

Ilícitude e Culpabilidade

Presente a tipicidade, não há elementos a indicar ou a criar séria dúvida de que a conduta tenha sido praticada em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou em exercício regular de direito, o que excluiria a ilicitude da conduta, de acordo com o artigo 23 do Código Penal.

À época dos fatos, o réu era maior de 18 anos, atendido o critério constitucional de imputabilidade (artigo 228 da Constituição Federal); e era plenamente capaz de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com esse entendimento, sem que haja elementos a indicar ou a criar séria dúvida de que não tivesse plena saúde mental, estivesse fortuitamente embriagado ou sob o efeito de substância psicoativa ou, ainda, sob dependência de droga (artigos 26 e 28 do Código Penal e do artigo 45 da Lei 11.343/2006).

Por fim, culturalmente inserido na sociedade brasileira, o réu tinha ao menos potencial consciência da ilicitude e não há elementos a indicar ou a criar séria dúvida de que lhe fosse inexigível conduta diversa, por estar sob coação irresistível ou agir em estrita obediência a ordem (artigo 22 do Código Penal).

Dosimetria

Passo à individualização da sanção penal exigida pelo artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, no procedimento trifásico do artigo 68, caput, do Código Penal, na medida em que necessária e suficiente à retribuição e à prevenção especial.

Na primeira etapa (artigo 59, incisos I e II, do Código Penal), aprecio as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis a partir da pena média, a fim de atender o princípio da isonomia do artigo 5º, caput, da Constituição Federal, pois “é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo. Não sendo, deve ela situar-se acima da previsão mínima feita pelo legislador. Esse é um ponto estratégico na individualização da pena, justamente para evitar a nociva padronização. A quem merece pena superior ao mínimo, deve o juiz saber aplicá-la, por uma questão de justiça.” (Guilherme de Souza Nucci, Curso de Direito Penal, v. 1, 3ª ed., 2019, Cap. XXXII, item 3.1, p. 1020). Do contrário, dar-se-ia idêntico tratamento para condutas de distinta reprovabilidade quando presentes exclusivamente circunstâncias judiciais favoráveis.

O nível de consciência do injusto e o grau de exigibilidade de comportamento diverso (cf. Juarez Cirino dos Santos, Direito Penal – Parte Geral, 5ª ed., 2012, p. 518-519) não destoam da culpabilidade já pressuposta na caracterização do crime. O acusado não ostenta Maus antecedentes, inexistindo condenação criminal transitada em julgado a ser valorada nesta fase, conforme exige a presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), nos moldes da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça e da tese com repercussão geral decidida pelo Supremo Tribunal Federal (RE 591054, Relator(a): Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2014).

Nada de desfavorável se comprovou a respeito da conduta social do acusado, o que, de qualquer modo, só justificaria sanção penal mais gravosa em função da prevenção especial positiva, prejudicada ante o “quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas” no sistema penitenciário brasileiro (STF, ADPF 347 MC, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015). Não tendo o titular da ação penal, neste ponto, se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, de rigor considerar favorável a conduta social do acusado, em atenção ao in dubio pro reo (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).

Não há elemento probatório seguro a respeito da personalidade do acusado, o que é questão técnica complexa e de, no mínimo, duvidosa convencionalidade (v. Corte Interamericana de Direitos Humanos, Fermín Ramírez vs. Guatemala, julgado em 20/06/2005).

Os motivos e as circunstâncias do crime não destoam do que é acobertado pelo tipo penal e não justificam imposição de sanção mais branda ou mais severa.

As consequências do crime são igualmente neutras, nesta fase, diante da extensão relevante, mas não excessiva, de atingimento ao bem jurídico tutelado.

A natureza e a quantidade da droga devem ser valoradas negativamente, diante da quantidade expressiva, superior ao suprimento anual de um usuário de droga, nos termos já adotados.

Por tudo isto, considero favorável a conduta social, desfavorável a natureza e quantidade da droga e neutras as demais circunstâncias. Nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06, atribuo peso equivalente a 1/5 para as circunstâncias relativas à natureza e a quantidade da droga, à personalidade e à conduta social do agente e 1/6 para as demais, tudo sobre o intervalo de pena em abstrato a cada circunstância favorável e desfavorável. A fração é eleita em interpretação sistemática da fração mínima das causas de aumento e diminuição expressas no Código Penal, aplicando-se sobre o intervalo em respeito ao papel do legislador na individualização da pena, de modo que possa alcançar, em tese, o piso ou o teto legais.

Fixo a pena-base em 10 anos de reclusão.

Na segunda etapa (artigos 61 a 67 do Código Penal), é de rigor a atenuação da pena em razão da confissão (artigo 65, inciso III, 'd', do Código Penal), ainda que parcial ou qualificada (cf. STJ, AgRg no AREsp 1763911/MG, Rel. Ministro Rogerio

Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/06/2021, DJe 24/06/2021; AgRg no AREsp 1754440/MT, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021), pois prepondera, aqui, a colaboração com a apuração criminal e a certeza do julgamento em detrimento do arrependimento e penitência pelo crime. Por conseguinte, observada a preponderância dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência, atenuo a pena em 1/6 sobre o intervalo de pena em abstrato.

Por fim, na terceira etapa, reduzo a pena de 2/3, no patamar máximo do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, do qual não se extrai critério seguro para gradação, em ofensa ao princípio da legalidade (artigo 5º, incisos II e XXXIX, da Constituição Federal), evitando-se, ainda, inadmissível bis in idem na dupla valoração das circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal combinado com o artigo 42 da Lei 11.343/06) na primeira e na terceira etapas.

Assim, fixo a pena privativa de liberdade em 2 anos, 9 meses e 10 dias.

Quanto à pena pecuniária, a gradação do número de dias-multa deve observar rigorosamente o sistema trifásico do artigo 68 do Código Penal, conforme tudo o que já se expôs.

Assim, correspondendo a pena-base a 1.000 dias-multa, fixo a pena de multa final em 278 dias-multa.

Ausentes elementos sobre a condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa, nos moldes do art. 49, § 1º, do CP, em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

Regime inicial

Deixo de promover a detração de que trata o artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, remetendo a questão ao juízo da execução. Com efeito, o preceito incluído pela Lei 12.736/12 confunde os institutos diversos da fixação do regime inicial e da progressão de regime e, deste modo, viola a Constituição Federal, que consagra a individualização da pena e a isonomia (artigo 5º, caput e incisos I e XLVI).

Diante da condenação a pena igual ou inferior a 4 anos, da primariedade dos acusados e das circunstâncias judiciais que não se mostram desfavoráveis, fixo o regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea 'c', do Código Penal (Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça e Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal).

É inaplicável ao tráfico privilegiado a previsão constante do artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.072/90, porque não se trata de crime equiparado a hediondo, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (HC 118533, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2016), ao que se curvou o Superior Tribunal de Justiça revendo a tese fixada em recurso repetitivo e cancelando a sua Súmula 512, para assentar que “o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo” (Pet 11.796/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 23/11/2016, DJe 29/11/2016).

Substituição e sursis

Diante das circunstâncias judiciais em torno do crime e do acusado (artigos 44, inciso III, e 59, inciso IV, do Código Penal) e do preenchimento dos requisitos objetivos dos incisos I e II do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade superior a 1 ano por duas restritivas de direitos, na forma do artigo 44, parágrafo 2º, do Código Penal, lembrando que o Senado Federal suspendeu a execução, nesta parte, da vedação disposta no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06 após decisão do Supremo Tribunal Federal.

A fim de atender às finalidades preventiva e retributiva da sanção penal e permitir, na medida do possível, a restauração dos efeitos do delito na comunidade, determino a substituição por prestação de serviços à comunidade ou a entidades pública (artigo 46 do Código Penal), a ser especificada e adaptada quando da execução (artigos 148 e 149 da Lei de Execução Penal), e pela interdição temporária de direitos do artigo 47, inciso III, do Código Penal, ficando o acusado com a suspensão ou proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo tempo da pena privativa de liberdade. Note-se que há vinculação

entre a suspensão do direito de dirigir e as circunstâncias em que cometido o crime, com o transporte da droga de uma cidade a outra.

Indicada a substituição da pena por restritiva de direitos (art. 44 do CP), é incabível a suspensão condicional da pena (art. 77, III, do CP), até porque aquela se mostra mais propícia à rápida ressocialização do acusado.

Dispositivo

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a pretensão acusatória para condenar MATHEUS MORRISEY SANTOS SILVA à pena de reclusão de 2 anos, 9 meses e 10 dias, em regime inicial aberto, e a 278 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, com a causa de diminuição do parágrafo 4º do mesmo dispositivo, substituída pelas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade e de interdição temporária do direito de dirigir.

Prisão preventiva

Nos termos do artigo 387, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal, aprecio e revogo a prisão preventiva, porque incompatível com o regime inicial de cumprimento de pena ora fixado. Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal: "a manutenção da prisão preventiva torna-se inadmissível quando condenação superveniente estabelece regime inicial menos gravoso que o fechado, porquanto a imposição de gravame maior do que aquele fixado no próprio título condenatório representa situação flagrantemente incompatível com o princípio constitucional da proporcionalidade." (HC 193996 AgR, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 21/12/2020). No mesmo sentido: HC 136397, Rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016.

Considerando a necessidade de garantir a ordem pública e, sobretudo, de assegurar a aplicação da lei penal, é necessário, adequado e suficiente a concessão da liberdade provisória mediante a determinação de a) comparecimento perante a autoridade policial ou judicial todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento; b) proibição de se ausentar da Comarca por mais de 8 dias sem prévia autorização do Juízo; c) comparecimento bimestral em juízo para informar e justificar suas atividades. Tudo na forma do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Assim, expeça-se, com urgência, os alvarás de soltura clausulados.

Custas

Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, condeno o réu ao pagamento das custas processuais (artigo 4º, parágrafo 9º, alínea 'a', da Lei Estadual 11.608/03). A gratuidade é questão a ser apreciada em momento oportuno, pelo juízo da execução, se o caso.

Providências Finais

Com o trânsito em julgado, expeça-se o mandado de prisão, se o caso, e a guia de recolhimento definitiva, nos termos do artigo 674 do Código de Processo Penal e da Resolução CNJ 113/2010; comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal; e comunique-se ao Instituto de Identificação Civil (artigo 709 do Código de Processo Penal).

Ainda com o trânsito em julgado, determine a destruição das amostras da droga guardadas para contraprova, nos termos do artigo 72 da Lei 11.343/06, comunicando-se à autoridade policial.

Também após o trânsito em julgado, atualize-se o histórico das partes no cadastro processual com a respectiva anotação; expeça-se a certidão de honorários ao advogado dativo, se o caso; expeça-se a competente certidão para execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa).

Comunicado o ajuizamento da execução da multa (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou verificada a prescrição da pretensão executória (evento 22), arquivem-se os autos com a movimentação 61619 no SAJ.

Int.

Mongaguá, 01 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA